

1500381-08.2022.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/07/2022
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500381-08.2022.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500381-08.2022.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052146/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 23198576 - 04º D.P. AMERICANA, 385/22/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2052146 - 04º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ AUGUSTO FANTACUSSI e outro
Réu Preso
Prioridade Idoso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

LUIZ AUGUSTO FANTACUSSI e ANDRÉ ROGERIO TRAPANI, qualificados nos autos, foram denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, no período noturno, agindo em concurso e em unidade de desígnio, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para o proveito comum, 10 quilos de cabos elétricos, avaliados em R\$300,00, pertencentes a A.A.P., pessoa maior de 60 anos de idade.

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 160/162). E, o aditamento de fls. 218/219, também foi recebido (fls. 220).
Os réus foram citados, apresentando defesa (fls. 194/200 e fls. 232).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, bem como os réus foram interrogados (fls. 247/248 e fls. 273/274).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 280/287), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada parcialmente procedente, apenas apara a exclusão da qualificadora da idade, com a conseqüente condenação dos réus pelo delito de furto qualificado.

A Doutora Defensora requereu a absolvição por falta de provas ou o reconhecimento da atenuante e afastamento das qualificadoras (fls. 290/296).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01, 08/12, e 13/15, e laudo de fls. 202/206.

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:
"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, os réus estavam na posse do bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor

doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

A vítima Antonio informou que é o proprietário e o local possui salões para locação. Durante a noite, foi acionado pelo vigilante do bairro, acerca da subtração da fiação. Disse, ainda, que dirigiu-se ao local, onde constatou danos, tendo em vista que as tampas da caixa onde estavam os fios foram quebradas, e os fios foram cortados. Narrou que compareceu a Delegacia, onde os objetos foram devolvidos, e informou que teve um prejuízo aproximado de mil reais.

Ainda, a testemunha Natan declarou que estava em sua casa, quando foi informado por uma vizinha da ação nas lojas próximas. Disse, ainda, que viu a ação dos réus arrancando os fios da caixa de energia, e a polícia foi acionada. Informou que quando os réus estavam saindo, os policiais chegaram ao local. Por fim, reconheceu os réus em Juízo.

Não há nos autos prova de que a vítima ou a testemunha conheciam os réus anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-los, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

O policial militar esclareceu que, por volta das 9h30min., foram informados de um possível furto em andamento, em um estabelecimento comercial. Disse, ainda, que chegando no local, verificaram dois indivíduos com sacolas em mãos, além de ferramentas e fios. Efetuada a abordagem, e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Informou que André carregava as ferramentas e o Luiz carregava uma

sacola com fios. Indagados, os réus alegaram que acharam os objetos na rua. Narrou, também, que o solicitante, o qual visualizou a subtração dos fios e acionou a polícia, e o proprietário, o qual reconheceu os objetos, compareceram a Delegacia. Por fim, a perícia foi solicitada ao local.

O réu Luiz, ouvido em Juízo, negou a prática do furto. Narrou que juntou recicláveis e os fios já estavam cortados e na rua.

E, o réu André, ouvido em Juízo, confirmou parcialmente a prática do furto. Declarou que usa drogas, sendo que acabou seu dinheiro, e iria penhorar a ferramenta de seu patrão, mas não conseguiu. Após, encontrou o Luiz, e depararam-se com o poste de energia. Disse que tirou os parafusos da caixa, sem danificar, e cortaram e retiraram os fios.

Em que pese a negativa acerca do dano na caixa de força, fato que restou refutado pelo laudo pericial, o réu confirma que danificou/cortou a fiação para a subtração.

Relativo a Luiz, sua negativa, em juízo, restou isolada no conjunto probatório, inclusive pelas declarações do comparsa.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra os acusados, inclusive acerca das qualificadoras, tendo em vista a comprovação do concurso pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas, e por um dos réus.

Ainda, a qualificadora de rompimento de obstáculo encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 202/206, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Assim, em que pese a defesa apresentada, não é possível o reconhecimento da exclusão da qualificadora ou desclassificação do delito.

Referente a qualificadora do repouso noturno, em estabelecimento comercial, resta caracterizada, tendo em vista ter o agente utilizado de período de menor vigilância da vítima.

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. (TEMA 1144, STJ - Recursos Especiais n. 1.979.989/RS en. 1.979.998/RS)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o

fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

No entanto, há que se analisar a recente Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema 1087 (Recursos Representativos – REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ), delimitando que: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Narra, ainda, o referido acórdão (REsp 1888756/SP):

“Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto”.

Assim, mesmo que a referida causa de aumento não possa ser individualmente aplicada, no presente caso, tendo em vista a ocorrência da qualificação no delito de furto, resta passível sua análise na primeira fase, como circunstância judicial.

Relativo a qualificadora da idade (art. 61, II, “h”, do CP), resta passível na jurisprudência a sua aplicação, tendo em vista sua natureza objetiva, com a presunção de vulnerabilidade da vítima idosa.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “h”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. PENA PECUNIÁRIA. VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II – Com efeito, em relação ao art. 61, II, “h”, do CP, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a sua incidência independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitativa, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida? (HC n. 427.179/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 05/03/2018). Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.722.345/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2019). III – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 722.948/SC, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

No entanto, há que se analisar que, no presente caso, não se verifica qualquer nexo entre a ação do réu e a condição de vulnerabilidade da vítima, tendo em vista tratar-se de imóvel comercial fechado. Desta forma, conforme manifestação, tanto do Ministério Público, quanto da Defesa, a referida qualificadora deve ser afastada.

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que

o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (RESP 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu André possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 83/113) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial.

No mais, em se tratando de furto duplamente qualificado (concurso e rompimento de obstáculo) e, ainda, levando-se em conta a sua ocorrência durante o repouso noturno, o qual é valorado como circunstância judicial negativa neste caso, há maior reprovabilidade da conduta dos acusados, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Exaspero, por isso, a pena base referente a André, em 1/3 (um terço), delimitando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. E para Luiz, em 1/4 (um quarto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu Luiz é reincidente (fls. 78/79) e o réu André é multirreincidente (fls. 83/113), circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal). Em relação a André, deve ser levada em conta a confissão, ainda que parcial. Por essa razão, acrescento às penas bases, para ambos, em 1/6 (um sexto), pelas reincidências, perfazendo um total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para André. E, para Luiz de 02 (dois)

anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto em razão de serem os réus reincidentes.

Os réus não poderão apelar em liberdade, por serem reincidentes. Além disso, os réus encontram-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

Os réus, por serem reincidentes, não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu LUIZ AUGUSTO FANTACUSSI à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, no piso, e o réu ANDRÉ ROGERIO TRAPANI à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no piso, como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal; bem como para condená-los no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

P. I. C.

Americana, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA